

NUR AGNES BINTI ABDULLAH @ CHOOI PUE YENG

LWN.

AHMAD BIN KAMARUDDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 2 Februari 2021 bersamaan 20 Jamadil Akhir 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-026-0121-2018]

[Rayuan Terhadap Penghakiman Ubah Perjanjian Hadhanah di Bawah Seksyen 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Pemohon : Tn. Abdul Razak Bin Muhidin daripada
Tetuan Abdul Razak Muhidin & Associates.**

**Peguam Syarie Responden : Pn. Noorhafizah Binti Abdul Aziz daripada
Tetuan Noorhafizah Abdul Aziz & Associates.**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu ke atas keseluruhan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam Selangor dalam Kes Saman No : 10200-026-0190-2016 yang telah diberikan pada 4/9/2018 sepertimana berikut -

- i. Mahkamah menolak Permohonan Plaintiff berdasarkan peruntukan Seksyen 76 Enakmen Undang-Undang keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah meluluskan Tuntutan Balas Defendan berdasarkan peruntukan Seksyen 76 Enakmen Undang-Undang keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- iii. Mahkamah memerintahkan Penghakiman Persetujuan Hadhanah Saman No. 10300-028-0589-2013 bertarikh 27 November 2014 adalah dibatalkan.
- iv. Mahkamah memerintahkan hak jagaan Anak yang bernama Danial bin Ahmad (No. Mykid: 080227-14-1231) (selepas ini dirujuk sebagai '*anak tersebut*') diberikan kepada Defendan sebagai bapa kandung.
- v. Plaintiff sebagai ibu kandung diberikan hak melawat anak tersebut pada bila-bila masa yang munasabah dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Defendan.
- vi. Plaintiff diberikan hak bersama dan bermalam dengan anak pada minggu pertama, minggu ketiga dan minggu kelima (sekiranya ada). Plaintiff dibenarkan mengambil anak tersebut di kediaman Defendan mulai jam 7.00 petang hari Jumaat dan dipulangkan semula kepada Defendan pada hari Ahad jam 6.00 petang.

vii. Mahkamah memerintahkan hak bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada Hari Raya Aidilfitri diberikan kepada Defendan, manakala Plaintiff akan bersama dengan anak tersebut pada Tahun Baru Cina.

viii. Mahkamah memerintahkan hak untuk bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada cuti persekolahan dibahagi sama rata antara Plaintiff dan Defendan.

[2] Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 9/8/2019 dan telah memfailkan Alasan Rayuannya pada 17/12/2018 dengan memplidkan lima (5) Alasan Rayuan sepertimana yang tertera di halaman 378 - 383, Rekod Rayuan iaitu :

- a. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menolak kesemua tuntutan Perayu tanpa menimbangkan bahawa Penghakiman Persetujuan Hadhanah telah mendatangkan kesukaran dan kepayahan ke atas anak mereka dalam memenuhi hak lawatan yang diberikan kepada Responden setiap hari dari Isnin hingga Jumaat, di samping hak bermalam pada setiap hujung minggu yang telah menjejaskan tumpuan dan pembelajaran beliau di SRJK Cina Kheow Bin serta memudharatkan kebajikan anak tersebut sehingga tidak mempunyai waktu berkualiti yang mencukupi untuk bersama-sama Perayu.

YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak menimbang bahawa Penghakiman Persetujuan Hadhanah telah meletakkan hak dan kepentingan Responden sebagai bapa mengatasi dan melebihi hak anak tersebut sebagai *mahdhun*

dan perlu untuk dipinda bagi memastikan kebajikan anak tersebut sentiasa terpelihara dan diutamakan seperti yang ditetapkan di bawah seksyen 87 (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS 2003];

- b. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak membuat apa-apa catatan atau rekod dalam nota keterangan mengenai temubual yang dijalankan oleh Mahkamah Bicara dengan anak tersebut pada 2/5/2018 yang mengandungi pilihan anak tersebut untuk tidak mahu tinggal lagi bersama-sama Perayu dan berhasrat untuk tinggal dengan Responden. Pilihan anak tersebut serta apa-apa alasan atau sebab mengapa anak tersebut memilih sedemikian adalah suatu keterangan yang amat penting dan material bagi membolehkan Mahkamah Bicara membuat keputusan untuk membatalkan Penghakiman Persetujuan Hadhanah bertarikh 27/11/2014 di bawah seksyen 77 EUUKIS 2003. Keputusan Mahkamah Bicara yang dibuat dalam ketiadaan sebarang catatan mengenai prosiding pilihan oleh anak yang dijalankan secara tertutup oleh Mahkamah Bicara dan tanpa kehadiran Perayu atau Responden atau wakil-wakil mereka dilihat tidak disandarkan kepada fakta material yang telah dibentangkan dalam prosiding
- c. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila hanya menimbangkan fakta bahawa anak tersebut telah mencapai umur yang membolehkan beliau membuat pilihan di bawah seksyen 87 (2) EUUKIS 2003 tanpa memeriksa dengan lebih lanjut sama ada anak tersebut telah memiliki kecerdikan dan kemampuan khusus

untuk menguruskan dirinya sendiri, kemampuan untuk membuat keputusan wajar berasaskan pertimbangan fakta dan keupayaan untuk memahami kesan dan akibat keputusan atau pilihan yang beliau lakukan yang ditetapkan oleh Hukum Syarak;

- d. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menerima secara total pilihan yang dibuat oleh anak tersebut tanpa menimbangkan bahawa Mahkamah Bicara adalah tidak terikat untuk mengikuti atau mengiktiraf pilihan anak tersebut sebelum Mahkamah Bicara berpuashati bahawa pilihan anak yang dibuat oleh anak tersebut tidak akan mendedahkan dirinya kepada keadaan yang boleh memudharatkan kebajikan dan maslahat anak tersebut; dan
- e. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak menimbangkan bahawa Perayu tidak melakukan sebarang perbuatan yang telah menggugurkan hak dan keutamaan Perayu untuk menjadi menjadi *hadhinah* kepada anak tersebut di bawah terma Penghakiman Persetujuan Hadhanah. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila gagal mengarahkan dirinya untuk melihat bahawa tidak ada sebarang perbuatan yang telah dilakukan oleh Perayu yang telah menghilangkan kelayakan untuk Perayu sebagai *hadhinah*.

Fakta Kes

[3] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 27/3/2006 dan bercerai pada 27/5/2013. Hasil daripada perkahwinan tersebut mereka telah dikurniakan dengan seorang cahaya mata lelaki pada 27/2/2008 yang diberi nama Danial Bin Ahmad. Pihak-pihak telah memperolehi satu keputusan berkaitan hadhanah dan lawatan anak tersebut melalui satu Penghakiman Persetujuan bertarikh 27/11/2014 melalui Kes Saman No. : 10300-028-0589-2013 sepertimana berikut –

- i) Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan anak yang bernama Danial Bin Ahmad (No. Sijil Kelahiran: 080227-14-1231) (anak tersebut) diberikan kepada Plaintiff.
- ii) Mahkamah memerintahkan hak lawatan, bersama dan bermalam adalah seperti berikut -
 - a) Bahawa hak lawatan dan bersama dengan anak tersebut diberikan kepada Defendan pada bila-bila masa yang sesuai dan munasabah secara khususnya setiap hari dengan diambil pada pukul 8.00 malam dan dipulangkan kepada Plaintiff pada pukul 10.00 malam, manakala pada hari Sabtu diambil pada pukul 10.00 pagi dan dipulangkan semula pada pukul 5.00 petang.
 - b) Bahawa hak lawatan, bersama dan bermalam dengan anak tersebut diberikan kepada Defendan setiap minggu dengan diambil pada hari

Jumaat jam 5.00 petang dan dipulangkan kepada Plaintiff pada hari Ahad jam 5.30 petang.

- c) Bahawa hak lawatan, bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada musim perayaan Hari Raya Aidil Fitri dan Hari Raya Aidil Adha adalah berdasarkan kepada perbincangan dan persetujuan pihak-pihak.
 - d) Bahawa hak lawatan, bersama dan bermalam pada musim cuti persekolahan penggal (cuti panjang) adalah diberikan secara sama rata di antara Plaintiff dan Defendan, manakala giliran dibuat atas perbincangan dan persetujuan kedua-dua pihak.
 - e) Bahawa hak lawatan, bersama dan bermalam pada cuti-cuti biasa (cuti pendek) adalah sama sebagaimana hak lawatan, bersama dan bermalam pada hari-hari biasa.
- iii) Mahkamah memerintahkan kedua-dua pihak dilarang menghasut, mempengaruhi, meracuni fikiran dan mengambil apa-apa tindakan yang menyebabkan anak tersebut membenci dan tidak menghormati satu pihak lain.
- iv) Mahkamah memerintahkan kedua-dua pihak perlu menjaga kebajikan anak tersebut ketika anak tersebut berada di bawah jagaan pihak-pihak.

- v) Mahkamah memerintahkan kedua-dua pihak hendaklah memberi kerja sama dan berbincang atas apa jua permasalahan yang timbul berkaitan anak tersebut demi menjaga kebajikan anak tersebut.
- vi) Mahkamah memerintahkan segala pertukaran alamat dan nombor telefon hendaklah dimaklumkan kepada pihak satu lagi.

[4] Pada 24/3/2016, Perayu telah memfailkan tuntutan untuk mengubah Penghakiman Persetujuan tersebut pada terma (ii) (a), (b) dan (e) seperti di atas dengan perenggan seperti berikut –

“ bahawa Defendan diberikan hak lawatan untuk berjumpa dengan anak tersebut pada hari Ahad minggu pertama dan ketiga setiap bulan bermula dari jam 4.00 petang hingga jam 8.00 malam pada hari Ahad ”

[5] Perayu juga membuat tuntutan untuk meminda terma (ii) (c) Penghakiman Persetujuan tersebut dengan perenggan seperti berikut –

“ Bahawa Defendan diberikan hak lawatan untuk berjumpa dan bermalam dengan anak tersebut selama tujuh (7) hari pada musim perayaan Hari Raya Aidil Fitri dan anak tersebut diberikan hak untuk bercuti bersama Plaintiff selama tujuh (7) hari pada musim perayaan Tahun Baru Cina ”

[6] Pada 2/8/2016, Responden / Defendan telah memfailkan Pembelaan dan Tuntutan Balas dengan menuntut supaya hak jagaan anak tersebut diserahkan kepada Responden / Defendan sebagai bapa kandung anak tersebut. Pada 4/9/2018, Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat para 1 (i) sehingga (viii) di atas.

[7] Akibat tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 13/9/2018. Sesalinan Notis Rayuan telah diserahkan kepada Peguam Syarie Responden / Defendan pada 18/9/2018. Hujahan Perayu difailkan pada 5/4/2019, Hujahan Responden difailkan pada 17/5/2019 dan Hujahan Jawapan Perayu difailkan pada 21/5/2019.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Perayu di dalam rayuan ini telah mengemukakan lima (5) Alasan Rayuan untuk diteliti dan dipertimbangkan oleh kami. Sukacita kami nyatakan sekali lagi bahawa kondisi anak yang menjadi '*subjek matter*' bagi kes ini adalah melibatkan seorang kanak-kanak lelaki yang telah mencapai umur 10 tahun 39 hari semasa keputusan Mahkamah Tinggi Syariah diberikan pada 4/9/2018, di mana kanak-kanak tersebut telah mumaiyiz dan keadaan ini berterusan sehingga hari ini.

[9] Kes rayuan ini adalah berbangkit daripada keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam terhadap tuntutan yang dibuat oleh Perayu untuk mengubah Penghakiman Persetujuan Hadhanah (Kes Saman No. : 10300-028-0589-2013) yang telah dikeluarkan pada 27/11/2014 melalui Kes Saman No. : 10200-026-0190-2018.

[10] Asas tuntutan yang dibuat oleh Perayu tersebut adalah semata-mata hanya untuk mengubah bentuk dan hak lawatan yang telah diberikan kepada Responden iaitu berkaitan hak lawatan harian dan hak lawatan dan bermalam bagi hujung minggu, dua hari raya dan cuti-cuti biasa (cuti pendek). Walaubagaimanapun,

Responden di dalam Tuntutan Balasnya pula memohon supaya hak penjagaan yang diberikan kepada Perayu diubah kepadanya. Penghakiman yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada 4/9/2018 telah memberikan hak penjagaan anak tersebut kepada Responden dan hak lawatan dan bermalam kepada Perayu.

[11] Melihat kepada situasi kes yang dirayu ini dan 5 Alasan Rayuan yang *diplidkan* oleh Perayu, kami dapati terdapat 4 isu rayuan yang perlu dinilai dan dipertimbangkan iaitu –

- i. Sama ada wujud atau tidak faktor yang *releven* untuk mengubah Penghakiman Persetujuan Hadhanah bertarikh 27/11/2014;
- ii. Sama ada Perayu hilang kelayakan sebagai penjaga anak atau sebaliknya;
- iii. Sama ada pilihan anak menyalahi peruntukan undang-undang dan Hukum Syarak; dan
- iv. Sama ada isu kebajikan dan / atau kemaslahatan anak dipertimbangkan atau sebaliknya.

Isu Pertama : Sama Ada Wujud Atau Tidak Faktor Yang *Releven* Untuk Mengubah Penghakiman Persetujuan Hadhanah Bertarikh 27/11/2014

[12] Bagi isu ini Pihak Perayu mengasaskan tuntutannya atas dakwaan telah berlaku perubahan matan yang material dalam hal keadaan yang mewajarkan untuk beberapa aspek berkaitan hak lawatan yang telah diberikan kepada Responden dalam Penghakiman tersebut untuk dipinda. Antara perubahan matan adalah berkaitan fakta persekolahan anak tersebut tidak wujud dalam Penghakiman Persetujuan yang dimeterai tersebut seperti jadual persekolahan yang ketat

termasuk kelas tuisyen, kemerosotan pencapaian dalam akademik dan pelaksanaan hak lawatan harian yang perlu dipatuhi. Gabungan faktor-faktor persekolahan anak tersebut adalah resepi yang telah menimbulkan kesukaran dan kepayahan kepada anak tersebut.

[13] Pihak Responden menyatakan bahawa Perayu telah membuat Permohonan Ubah Perintah atas alasan telah berlaku perubahan matan yang amat material yang membolehkan Penghakiman Persetujuan diubah mengikut kesesuaian perubahan yang berlaku. Titik tolak daripada permohonan tersebut yang wujudnya cubaan menyekat hak Responden selaku ayah kandung kepada anak tersebut untuk melawat, memberi didikan yang sempurna serta mengurangkan tempoh masa melawat dan bermalam tersebut.

[14] Bagi isu ini, YA Hakim Bicara di dalam Penghakimannya (halaman 349-350 Rekod Rayuan) menyatakan –

[15] Perintah yang hendak diubah adalah perintah yang diasaskan kepada persetujuan kedua-dua pihak pada 27 November 2014. Berdasarkan Perintah Persetujuan tersebut Mahkamah melihat ada 2 aspek yang perlu diperhalusi oleh Mahkamah iaitu –

Pertama – Perintah tersebut bukan diasaskan atas sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta atau berlaku perubahan matan tentang hal keadaan anak atau pihak-pihak tersebut. Perintah tersebut bukan diasaskan kepada keadaan sebenar pada masa ia dikeluarkan bahkan semata-mata atas pertimbangan persetujuan dari kedua-dua pihak.

Kedua – Perintah Persetujuan pada dasarnya tidak boleh diubah berdasarkan kaedah *fiqhiyyah* sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis yang bermaksud : “Orang-

orang terikat dengan perjanjian di antara mereka". Akan tetapi apabila persetujuan itu melibatkan kepentingan anak, maka undang-undang membenarkan ia diubah. Dalam hal ini, seksyen 77 EUUKIS 2003 menetapkan seperti berikut : "Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah syarat-syarat sesuatu perjanjian berhubung dengan penjagaan atau nafkah seseorang anak, sama ada perjanjian itu dibuat sebelum atau selepas tarikh yang ditetapkan, walau apa pun peruntukan yang berlawanan dalam perjanjian itu, jika Mahkamah berpuas hati bahawa adalah munasabah dan untuk kebajikan anak itu berbuat demikian"

[16] Berdasarkan peruntukan ini, Plaintiff boleh mengubah perintah mengenai penjagaan anak yang diasaskan kepada persetujuan jika perintah itu telah tidak membawa kepada kemaslahatan dan kebajikan anak sekalipun permohonan itu berlawanan dengan apa yang telah dipersetujui sebelum ini. Asasnya ialah Plaintiff perlu menunjukkan bahawa perintah tersebut tidak harus dikekalkan kerana ia menjejaskan hak Plaintiff dan kebajikan anak tersebut.

[15] Bagi suatu tindakan untuk mengubah mana-mana perintah atau penghakiman tentang hadhanah, maka ia hendak memenuhi salah satu atau kedua-dua peruntukan ini iaitu seksyen 76 dan seksyen 77 EUUKIS 2003 sepertimana berikut –

Seksyen 76 - Kuasa Bagi Mahkamah Mengubah Perintah Mengenai Penjagaan Atau Nafkah Seseorang Anak

Mahkamah boleh, atas permohonan seseorang yang ada mempunyai kepentingan, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah, atau boleh pada bila-bila masa membatalkan, sesuatu perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak, jika Mahkamah berpuas hati bahawa perintah itu telah diasaskan atas sesuatu salah

pernyataan atau kesilapan fakta atau jika sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan.

Seksyen 77 - Kuasa Bagi Mahkamah Mengubah Perjanjian Penjagaan Atau Nafkah Seseorang Anak

*Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah syarat-syarat sesuatu perjanjian berhubung dengan penjagaan atau nafkah seseorang anak, sama ada perjanjian itu dibuat sebelum atau selepas tarikh yang ditetapkan, walau apa pun peruntukan yang berlawanan dalam perjanjian itu, jika Mahkamah berpuas hati bahawa **adalah munasabah dan untuk kebajikan anak itu** berbuat demikian.*

[16] Bagi peruntukan seksyen 76 EUUKIS 2003 ini terdapat dua elemen penting yang perlu dinilai iaitu –

- i. Jika perintah yang dikeluarkan terdahulu telah diasaskan atas sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta. Bagi elemen ini, Plaintiff hendaklah membuktikan bahawa YA Hakim Bicara telah memutuskan perintah / penghakiman tersebut bersandarkan kepada pernyataan yang salah atau fakta yang silap ; atau
- ii. Jika sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan. Bagi elemen ini, ia berkaitan dengan perubahan matan, di mana boleh dinilai dari beberapa aspek iaitu –
 - a. Bagi perubahan tentang tempoh masa – ia berkait rapat dengan umur kanak-kanak tersebut di mana sudah tentu umur kanak-kanak tersebut berubah bila berlakunya perubahan masa tempoh masa sama ada

peningkatan umur kanak-kanak tersebut dan perubahan dari alam belum mumaiyiz kepada alam mumaiyiz.

- b. Bagi perubahan keadaan – ia berkaitan dengan perubahan kepada keadaan-keadaan baru yang mendatang seperti pemasalahan pelaksanaan perintah / penghakiman hadhanah yang diberikan.
- c. Bagi perubahan kepada hak-hak khusus – adalah berkaitan dengan penjagaan yang melibat kehendak pihak-pihak yang bertikai dan kanak-kanak tersebut itu sendiri.

[17] Bagi peruntukan seksyen 77 EUUKIS 2003, adalah berkaitan dengan hak untuk mengubah perjanjian penjagaan / hadhanah. Apa-apa persetujuan yang telah direkodkan sebagai Penghakiman Persetujuan selaras dengan seksyen 131 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 adalah mempunyai kesan dan sifat seperti perintah lain dan ia bukan lagi sebagai suatu perjanjian. Sesuatu persetujuan yang telah diendoskan sebagai Penghakiman Persetujuan adalah tertakluk kepada Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 5 Tahun 2006 yang menyatakan sepertimana berikut –

Arahan Amalan No. 5 Tahun 2006
Kesan Perjanjian Persetujuan Sulh

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A. kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia Tahun 2006 pada 12 hingga 14 April, 2006 bersamaan 13 hingga 15 Rabiulawwal, 1427H di Shah Alam, Selangor yang telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan bahawa kesan

perjanjian persetujuan Sulh yang menepati kehendak Hukum Syarak yang telah direkodkan dan disahkan oleh Mahkamah tidak boleh ditarik balik dan tidak boleh dirayu oleh pihak-pihak yang terlibat dengan perjanjian persetujuan tersebut.

[18] Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah tersebut, sesuatu Penghakiman Persetujuan Hadhanah adalah tidak boleh ditarik balik ataupun dirayu, namun begitu ia tidak menghalang pemfailan kes tuntutan mengubah penghakiman persetujuan tersebut berdasarkan seksyen 77 EUUKIS 2003 tersebut. Merujuk kepada kes ***Babji Bin Babjan lwn. Zainab Binti Mohd Saleh***, JH 29 (2) menyatakan bahawa asas untuk mengubah sesuatu penghakiman persetujuan tersebut apabila wujudnya keadaan munasabah untuk berbuat demikian dan perkara tersebut adalah semata-mata untuk kebajikan anak-anak.

[19] Tindakan Plaintiff memfailkan tuntutan untuk mengubah Penghakiman Persetujuan bertarikh 27/11/2014 kerana wujudnya perubahan matan iaitu umur anak tersebut dari berumur 6 tahun 9 bulan ketika Penghakiman Persetujuan telah meningkat umur 10 tahun 39 hari semasa keputusan Mahkamah Tinggi Syariah diberikan pada 4/9/2018. Asas tuntutan ubah Penghakiman ini juga berkaitan dengan kewujudan permasalahan pelaksanaan Penghakiman Persetujuan tersebut apabila anak tersebut telah memasuki alam persekolahan secara formal yang melibatkan hak lawatan harian dan hak bermalam pada hujung minggu. Keadaan yang wujud ini, secara tidak langsung menyebabkan pihak satu lagi ternafi haknya dan perkara ini telah menyebabkan soal kebajikan anak tersebut perlu dinilai semula.

[20] Oleh itu, kami berpuas hati bahawa tindakan YA Hakim Bicara mempertimbangkan tuntutan Perayu dan tuntutan balas Responden bagi mengubah Penghakiman Persetujuan bertarikh 27/11/2014 adalah diasaskan kepada faktor yang *relevan* dan selari dengan kehendak undang-undang.

Isu Kedua : Sama Ada Perayu Hilang Kelayakan Sebagai Penjaga Anak Atau Sebaliknya

[21] Isu ini adalah berkaitan Alasan Rayuan Perayu yang kelima iaitu berhubungkait dengan isu kelayakan sebagai Penjaga anak tersebut. Pihak Perayu menyatakan bahawa Responden di dalam Tuntutan Balasnya mendakwa bahawa Perayu telah hilang kelayakan atas 2 alasan iaitu dengan sengaja tidak berakhlak dengan akhlak Islamiyah dan telah mencuai kebajikan anak tersebut dengan cara -

- a. Memukul dan mengugut anak tersebut;
- b. Anak disediakan makanan tidak seperti khinzir ketika di rumah ibu Perayu yang bukan beragama Islam;
- c. Tidak memberi dan melengkapkan anak tersebut dengan pendidikan agama;

[22] Pihak Perayu menghujahkan bahawa Responden gagal membawa keterangan sehingga melepasi beban pembuktian yang menunjukkan bahawa Perayu hilang kelayakan di bawah seksyen 84 EUUKIS 2003 dan seksyen 72, 73 dan 74 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Perayu menghujahkan hak Perayu sebagai penjaga anak tersebut di bawah Penghakiman Persetujuan hanya boleh dibatalkan dan diberikan kepada Responden sekiranya mana-mana syarat perlantikan Penjaga gagal dipenuhi atau dilanggar oleh Perayu.

[23] Melalui penelitian kami terhadap Rekod Rayuan, kami dapati di dalam Pernyataan Tuntutan Balas Defenden / Responden (lihat halaman 38 – 39 Rekod Rayuan) ada mendakwa bahawa Plaintiff / Perayu telah hilang kelayakan atas sebab sengaja tidak berakhlak dengan akhlak Islamiyah dan telah mencuaikan kebajikan anak tersebut.

[24] Setelah meneliti Rekod Rayuan berkali-kali, kami bersetuju dengan hujahan Perayu bahawa Responden telah gagal membuktikan dakwaannya bahawa Perayu telah hilang kelayakan sebagai penjaga kepada anak tersebut. YA Hakim Bicara juga tidak mengulas tentang isu ini di dalam Alasan Penghakimannya, sebaliknya hanya menyatakan bahawa bahawa—

“Dalam hal ini, Mahkamah mendapati Defenden berkelayakan dan memenuhi syarat sebagai hadhinah sebagaimana yang dijelaskan di atas”

[25] Oleh yang demikian, atas prinsip الأصل آدم (*asal sesuatu itu tiada*) kami berpuashati menyatakan bahawa Perayu tidak hilang kelayakan untuk menjadi Penjaga anak tersebut. Kami juga berpuashati berdasarkan Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara bahawa Responden mempunyai kelayakan dan memenuhi syarat sebagai penjaga anak tersebut.

[26] Sukacita kami nyatakan di sini, seseorang penjaga itu mestilah memenuhi syarat-syarat kelayakan sepertimana kehendak peruntukan seksyen 83 EUUKIS 2003. Hak seorang perempuan itu akan hilang bilamana ia telah memenuhi salah satu keadaan sepertimana yang dinyatakan di dalam peruntukan seksyen 84

EUUKIS 2003. Manakala keadaan seseorang lelaki hilang itu kelayakan terhadap hadhanah hanya dinyatakan di dalam Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 15 Tahun 2007 sepertimana berikut –

Arahan Amalan No. 15 Tahun 2007
Alasan Yang Menyebabkan Hak Jagaan Seseorang Bapa
Atau Pihak Sebelah Lelaki Hilang Kelayakan

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil. 1 Tahun 2007 pada 28hb. hingga 30 Rabiulawwal, 1428H bersamaan 16hb. hingga 18hb. April 2007 di Melaka dan pengesahan Mesyuarat Ketua-Ketua Hakim Syarie Negeri Seluruh Malaysia Kali Ke 42 pada 25 Jamadilawwal, 1428H bersamaan 11 Jun, 2007M telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung dengan bagaimana hak jagaan seseorang bapa atau seseorang lelaki lain boleh hilang kelayakan terhadap hadhanah, antaranya ialah -

- a. jika dia berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka ;*
- b. jika dia murtad ;*
- c. jika dia mencuaikan atau menganiaya kanak-kanak itu ;*
- d. jika dia menjadi tidak sempurna akal ;*
- e. jika dia berpenyakit kusta, sopak atau penyakit-penyakit lain yang berjangkit yang membahayakan kanak-kanak itu.*

[27] Oleh yang demikian, apabila seseorang itu berjaya dibuktikan bahawa ia telah hilang kelayakan terhadap hadhanah melalui seksyen 84 EUUKIS atau Arahan Amalan Mahkamah Syariah No 15 Tahun 2007, maka hak penjagaan itu akan berpindah kepada mana-mana pihak lain yang berkelayakan. Bagi rayuan ini, kami setuju bahawa Perayu tidak hilang kelayakan untuk menjadi penjaga anak

tersebut, namun begitu perubahan penjagaan anak tersebut bukan sahaja melihat kepada kelayakan semata-mata malah perkara lain juga diambil kira. Berdasarkan penelitian kami, Perayu dan Responden memenuhi kelayakan untuk menjadi penjaga kepada anak tersebut.

Isu Ketiga : Sama Ada Pilihan Anak Menyalahi Peruntukan Undang-Undang Dan Hukum Syarak

[28] Bagi isu ini adalah berkait rapat dengan Alasan Rayuan Kedua, Ketiga dan Keempat. Kami dapati semasa tuntutan ubah Penghakiman Persetujuan ini difailkan, anak tersebut telah mencapai umur 10 tahun 39 hari semasa keputusan Mahkamah Tinggi Syariah diberikan pada 4/9/2018. Berdasarkan umur anak tersebut, kami merujuk peruntukan seksyen 85 EUUKIS 2003 menjelaskan tentang umur mumaiyiz sepertimana berikut –

Seksyen 85 - Lamanya penjagaan

(1) Hak hadinah bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur tujuh tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan hadinah, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sebelas tahun, jika kanak-kanak itu perempuan.

(2) Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.

[29] Melihat situasi umur anak tersebut, kami berpuashati menyatakan bahawa anak tersebut telah memasuki umur mumaiyiz yang mempunyai hak untuk membuat pilihan untuk tinggal sama ada dengan ibu atau bapanya. Selepas anak tersebut telah mencapai umur mumaiyiz. Berdasarkan peruntukan seksyen 85 (2) EUUKIS 2003, hak hadhinah telah tamat apabila anak tersebut mencapai umur mumaiyiz dan penjagaan anak tersebut akan turun kepada bapa. Walau bagaimanapun penentuan penjagaan bagi anak mumaiyiz ini adalah tertakluk kepada pilihan anak dan juga imbalan isu kebajikan sepertimana kehendak seksyen 87 (2) EUUKIS 2003.

[30] Tindakan anak yang mumaiyiz diberi pilihan untuk membuat pilihan penjaganya sepertimana yang dinyatakan dalam peruntukan seksyen 85 (2) serta seksyen 87 (2) (b) EUUKIS 2003 adalah selari dengan nas syarak sepertimana berikut –

- i. Imam As-Syafie di dalam kitab *Al-Umm*, Juzu' 5, Beirut : Dar Al-Qutaibah. menyatakan –

قال الشافعي : فاذا افترق الأبوان وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج وما كانوا صغارا فاذا بلغ أحدهم سبعا أو ثمانا سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمه وكان عند أيهما اختار

Maksudnya: “As-Shafie berkata : “Apabila berpisah kedua ibu bapa dan kedua-duanya berada dalam satu qariah maka ibu adalah lebih berhak terhadap anaknya selama ia belum berkahwin lain dan semasa anak-anak itu masih kecil. Apabila genap umur mereka tujuh tahun atau lapan

tahun dan ia sempurna akal ia disuruh pilih di antara bapa dan ibunya dan ia akan bersama dengan siapa yang dipilih”

ii. Hadis Rasulullah s.aw yang berbunyi –

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد سقاني من بئر أبي عتبة ، وقد نفعتني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إستهما عليه) فقال زوجها : من يحاقني في ولدي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (هذا أبوك ، وهذه أمك ، فخذ بيد أيهما شئت) فأخذ بيد أمه ، فانطلقت به .

Maksudnya : “Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya; Telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah s.aw seraya berkata: “Wahai Rasulullah s.aw sesungguhnya suamiku hendak membawa anakku bersamanya, sedangkan anakku telah menolongku mengambil air daripada telaga Abi ‘Inabah (iaitu sebuah telaga di Madinah Munawwarah) dan anakku banyak memberi faedah kepadaku daripada pertolongannya itu. Maka Sabda Rasulullah s.a.w; Hendaklah kamu berdua membuang undi tentang anak kamu, maka suaminya itu menjawab “Siapakah yang boleh menghalang hakku tentang anakku ini.” Lalu Baginda Rasulullah s.a.w berkata kepada anak itu agar membuat pilihan sama ada ingin tinggal dengan ibunya atau mengikut bapanya dengan sabdanya; “Ini bapa kamu dan ini juga ibu kamu, maka pilihlah siapa di antara kedua-duanya yang engkau suka tinggal bersama”. Maka anak itu pun memilih ibunya dengan memegang tangan ibunya itu, lalu perempuan itu pun membawa anaknya itu pulang bersamanya (Riwayat Abu Daud 2/ 283 Kitab Al-Talaq)”

- iii. Menurut pandangan Imam Muhammad Bin Ismail Al-Yamani As-Shon'aani di dalam kitabnya *Subul As-Salam*, Jilid 3, Hlm. 228, Beirut Lubnan : Dar Al-Fikr menyatakan –

فقد دل الحديث على أنه بعد إستغناء الصغير بنفسه ، يخير بين أبويه

Maksudnya : “Hadis di atas menunjukkan bahawa kanak-kanak yang sudah boleh menguruskan dirinya dengan sendiri diberi pilihan untuk tinggal dengan salah seorang daripada kedua ibubapanya”

- iv. Imam Ibnu al-Qaiyyim di dalam kitabnya *A'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid 2, Hlm. 249, Beirut : Maktabah Hadhariyyah berkata –

تخير الولد بين أبويه ثابت بالسنة الصحيحة المحكمة

Maksudnya : “Hak pemilihan anak untuk tinggal sama ada dengan ibunya atau dengan bapanya ada sabit terdapat di dalam sunah yang sahih”

[31] Banyak penghakiman telah menghuraikan tentang hak anak yang mumaiyiz ini untuk membuat pilihan penjaganya, antaranya kes *Halistina Binti Mohd Noor lwn. Shafirin Bin Salleh*, JH 41 (1), *Harwati Binti Zakaria lwn. Engku Aminuddin Bin Engku Ibrahim*, JH 41 (1), *Hazlan Bin Abdul Hakim lwn. Zhibek Suleyeva* Kes Rayuan (Selangor) No. : 10000-028-0015-2017, Kes *Norchaya Binti Talib lwn. Azmi Bin Sharom*, Kes Rayuan (Selangor) No. : 10000-028-0020-2017, *Anwar Hasni Bin Nayan @ Abu Hassan lwn. Nurliza*

Binti Ahmad, Kes Rayuan (Pulau Pinang) No. : 07000-028-0002-2017 dan banyak lagi.

[32] Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa tindakan YA Hakim Bicara memanggil anak tersebut untuk ditemubual dan membuat pilihan penjaganya adalah suatu tindakan yang berlandaskan undang-undang dan Hukum Syarak. Walaubagaimanapun kami bersetuju dengan rujukan kes yang dikemukakan oleh Perayu iaitu kes **Rooseliwati Binti Hussein lwn. Syed Farouk Azlan Bin Syed Abdul Aziz**, JH 36 (1) sepertimana berikut –

“Dalam kes ini kedua-dua anak tersebut telah mencapai umur yang membolehkan mereka memilih sama ada untuk tinggal bersama ibu atau bapa meeka. Aida telah berumur 12 tahun, manakala Fazril telah berumur 14 tahun. Walaubagaimanapun tidak semestinya Mahkamah memutuskan hak penjagaan itu kepada pihak yang dipilih oleh anak-anak tersebut kerana Mahkamah akan mengimbangi pilihan anak-anak dan kebajikan mereka”

[33] Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di dalam kes **Muhammad Riduan Bin Baba lwn. Hazlinda Binti Abdul Hamid**, Hamid (Kes Semakan (Selangor) No : 10000-003-0015-2011 pula menjelaskan bahawa keterangan ibu bapa diperlukan dalam merealisasikan kehendak seksyen 87 (2) EUUKIS 2003 sepertimana berikut -

“Seterusnya, dijelaskan lagi di dalam seksyen tersebut bahawa pertimbangan untuk memastikan kebajikan anak terpelihara hendaklah mengambilkira kemahuan-kemahuan ibu bapa anak dan juga kemahuan anak yang perlukan jagaan. Ini bermakna, menjadi keperluan seksyen 87(2) itu bahawa Hakim Bicara hendaklah mengambil keterangan ibu bapa atau pihak yang memohon jagaan dan juga keterangan anak. Keterangan ibu bapa

dan anak sangat penting untuk membolehkan Hakim dibentangkan fakta sebanyak mungkin berkaitan hal keadaan yang boleh memenuhi keperluan-keperluan fizikal anak, keadaan persekitaran yang boleh memberi kesan emosi, mental, pemikiran dan agama anak. Perkataan “dan” yang menjadi penghubung seksyen 87(2)(a) dan 87(2)(b) menunjukkan tiada pilihan untuk hanya mengambil kira kemahuan salah seorang sahaja. Oleh yang demikian, kegagalan seseorang Hakim Bicara mengambil keterangan ibubapa dan anak, telah menjejaskan keperluan undang-undang di dalam seksyen 87(2) tersebut melainkan wujud alasan yang munasabah bahawa keterangan ibu bapa dan anak secara zahir adalah tidak wajar diambil, atau terdapat persetujuan oleh kedua-dua pihak yang bertikai atau keadaan anak tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan di dalam seksyen 86(2)(b) itu. “

[34] Merujuk kepada Alasan Penghakiman (halaman 355, Rekod Rayuan), kami dapati YA Hakim Bicara telah memanggil anak tersebut untuk ditemubual dan membuat pilihan penjaganya pada 2/5/2018. Hasil daripada temubual tersebut, YA Hakim Bicara menyatakan bahawa anak tersebut membuat pilihan untuk tinggal dengan bapanya (Responden) dan YA Hakim Bicara menerima pilihan anak tersebut tanpa menyatakan dengan jelas pertimbangan lain terutamanya isu kebajikan terhadap anak tersebut.

[35] Kami juga dapati bahawa YA Hakim Bicara tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Perayu dan Responden, sebaliknya bergantung semata-mata kepada pilihan anak tersebut sahaja. Kami bersetuju dengan hujahan Perayu bahawa tidak wujud sebarang persetujuan yang dicatatkan oleh YA Hakim Bicara bahawa kedua-dua pihak bersetuju untuk memberi mandat kepada Mahkamah agar pilihan oleh anak tersebut dijadikan asas kepada penghakiman kes tersebut. Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa

penghakiman yang diberikan oleh YA Hakim Bicara adalah dibuat daripada pertimbangan yang tidak menyeluruh.

[36] Berhubung dengan temubual anak tersebut pada 2/5/2018, kami dapati bahawa YA Hakim Bicara telah merekodkan temubual tersebut dengan lengkap iaitu pada 2/5/2018 jam 8.41 pagi. Kewujudan Alasan Rayuan Perayu Kedua dan Ketiga adalah berhubungkait dengan rekod catatan temubual yang mana Perayu gagal perolehi bersama-sama dengan Nota Keterangan yang lain. Walaupun perkara tersebut telah terjadi, hakikatnya temubual anak tersebut telah dibuat pada 2/5/2018 dan direkodkan bahawa anak tersebut telah memilih untuk tinggal dengan Responden.

[37] Melalui penelitian kami terhadap catatan temubual anak tersebut, kami dapati bahawa jawapan yang diberikan oleh anak tersebut menunjukkan beliau seorang kanak-kanak yang cerdik dan boleh membezakan antara yang baik dan sebaliknya. Oleh yang demikian, pilihan anak yang dinyatakan oleh YA Hakim Bicara di dalam Alasan Penghakimannya adalah dari kehendak dan pilihan anak tersebut di mana anak tersebut memilih untuk tinggal dengan Responden.

Sama Ada Isu Kebajikan Dan / Atau Kemaslahatan Anak Dipertimbangkan Atau Sebaliknya

[38] Isu kebajikan dan / atau kemaslahatan ini adalah menjadi asas yang utama dinyatakan pada peruntukan seksyen 77 EUUKIS 2003 bagi mengubah sesuatu perjanjian persetujuan berhubung dengan hadhanah iaitu –

*“Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah syarat-syarat sesuatu perjanjian berhubung dengan penjagaan atau nafkah seseorang anak, sama ada perjanjian itu dibuat sebelum atau selepas tarikh yang ditetapkan, walau apa pun peruntukan yang berlawanan dalam perjanjian itu, jika Mahkamah berpuas hati bahawa adalah **munasabah dan untuk kebajikan** anak itu berbuat demikian”*

[39] Peruntukan tersebut hendak juga selari dengan peruntukan seksyen 87 (2) EUUKIS 2003 yang mementingkan isu kebajikan sebagai pertimbangan utama -

*“(2) Untuk memutuskan dalam jagaan siapakah seseorang kanak-kanak patut diletakkan, pertimbangan yang utama ialah **kebajikan kanak-kanak** itu dan, tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada –*

(a) kemahuan-kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu; dan

(b) kemahuan-kemahuan kanak-kanak itu, jika dia telah meningkat umur dapat menyatakan sesuatu pendapatnya sendiri.

[40] Oleh yang demikian, pertimbangan terhadap kebajikan anak tersebut berdasarkan seksyen 87 (2) EUUKIS 2003 sewajarnya dilihat daripada dua sudut iaitu melalui kemahuan-kemahuan ibu dan bapa anak tersebut dan melalui kemahuan anak tersebut yang telah meningkat umur mumaiyiz selari dengan seksyen 85 EUUKIS 2003.

[41] Bagi kemahuan anak tersebut, kami berpuashati bahawa anak tersebut telah menyatakan keinginannya untuk tinggal dengan Responden melalui temubual yang dijalankan pada 2/5/2018. Anak tersebut semasa temubual menyatakan tentang kehendaknya yang ingin bersolat, di mana di rumah ibunya dia tidak bersolat,

sebaliknya dia boleh bersolat di rumah bapanya, sedangkan ibunya tidak bersolat dan tidak tahu solat.

[42] Bagi kemahuan Perayu (ibu), melalui tuntutan dan keterangannya mahu mengubah bentuk dan hak lawatan yang telah diberikan kepada Responden melalui Penghakiman Persetujuan iaitu berkaitan hak lawatan harian dan hak lawatan dan bermalam bagi hujung minggu, dua hari raya dan cuti-cuti biasa (cuti pendek). Asas tuntutan Perayu tersebut dibuat disebabkan kepadatan masa dalam melaksanakan terma Penghakiman Persetujuan tersebut, di mana anak tersebut hilang tumpuan dalam setiap pembelajaran yang menjadikan anak tersebut lemah dalam bidang akademik.

[43] Perayu mendakwa anak tersebut sering kepenatan dan semakin hilang daya tumpuan untuk belajar. Anak juga mengadu tidak pernah suka apabila dibawa ke rumah kediaman Defenden pada setiap hari. Bagi pendidikan anak tersebut, didikan berbentuk keagamaan, Perayu hanya bergantung kepada silibus Pendidikan Agama Islam yang diajar di sekolah semata-mata, manakala bagi silibus lain, Perayu menghantar anak tersebut ke pusat tuisyen.

[44] Merujuk kemahuan Responden (bapa), Responden tidak bersetuju dengan tuntutan Perayu disebabkan tidak dapat menunaikan tanggungjawab sebagai bapa bagi mendidik anak tersebut dan tidak dapat meluang banyak masa untuk pendidikan agama dan fardhu ain anak tersebut. Responden menuntut supaya penjagaan anak tersebut diberikan kepadanya kerana ingin memberikan pendidikan agama dan fardhu ain kepada anak tersebut. Responden juga pernah mendaftarkan anak tersebut di Sekolah Agama Rakyat Kafa (1) At-Taiyyibin, Taman Bidara

Selayang tetapi Perayu tidak pernah menghantar anak tersebut ke sekolah berkenaan.

[45] Melalui penelitian kami terhadap Alasan Penghakiman, kami dapati YA Hakim Bicara pada halaman 356 Rekod Rayuan menyatakan –

“Seterusnya Mahkamah juga akan mengambil kira kemaslahatan dan kebajikan anak tersebut sebelum ditentukan hadhinahnya mahupun menimbangkan permintaan atau pilihan anak-anak tersebut.....”

[46] Walaupun kenyataan tentang kemaslahatan dan kebajikan dinyatakan oleh YA Hakim Bicara, kami tidak menemui sebarang ulasan mengenai asas kebajikan yang dinilai melalui kemahuan Perayu atau Responden kecuali kemahuan anak tersebut yang ingin tinggal dengan Responden. Oleh itu, kami berpuashati bahawa YA Hakim telah terkhilaf apabila gagal menyatakan kebajikan dan / atau kemaslahatan sebagai asas pertimbangan utama penentuan penjagaan anak tersebut selain pilihan anak tersebut.

[47] Justeru itu, kami perlu campurtangan dan menilai semula pertimbangan kebajikan bagi penentuan penjagaan anak tersebut. Merujuk kepada kehendak Perayu dan Responden, kami dapati kehendak Responden adalah lebih besar kerana ia melibatkan perubahan kepada penjagaan anak tersebut, sedangkan kemahuan Perayu hanya berhubungkait dengan hak lawatan harian dan hak lawatan dan bermalam bagi hujung minggu, dua hari raya dan cuti-cuti biasa (cuti pendek) bagi Penghakiman Persetujuan tersebut semata-mata.

[48] Melalui penelitian keterangan Perayu dan Defenden di dalam Rekod Rayuan, kami dapati isu kebajikan yang utama terhadap anak tersebut adalah soal

didikan agama dan fardhu ain. Bagi isu ini, Perayu hanya bergantung kepada silibus Pendidikan Agama Islam di sekolah semata-mata, sedangkan fokus Responden terhadap soal didikan agama dan fadhu ain kepada anak tersebut melibatkan didikan di rumah dengan pelaksanaan solat, puasa dan pengajian Al-Quran selain pengajian di Sekolah Agama atau KAFA.

[49] Isu kebajikan terhadap anak tersebut ini adalah selari dengan kemahuan anak tersebut yang mahu bersolat dan di rumah Respondenlah ia boleh berbuat demikian, berbanding di rumah Perayu. Oleh itu, kami berpuasahati isu kebajikan ini demi menjaga *maqasid syariyyah* terhadap agama anak tersebut, maka penentuan penjaga anak tersebut wajar dipinda kepada Responden selari dengan pilihan anak tersebut.

[50] Bagi rayuan ini walaupun Perayu berjaya menunjukkan bahawa YA Hakim Bicara terkhilaf semasa membuat pertimbangan terhadap keputusan pada 4/9/2018, namun ianya tidak mampu untuk mengubah keputusan tersebut kerana pilihan anak yang dibuat adalah menepati kebajikan dan / atau kemaslahatan anak tersebut. Oleh yang demikian, kami terpaksa menolak rayuan Perayu ini.

[51] Memandangkan rayuan Perayu adalah ditolak dan Responden mendapatkan hak penjagaan anak tersebut, maka kami berpuashati menyatakan bahawa kos prosiding rayuan ini sewajarnya ditanggung oleh masing-masing pihak.

[1] Akhir sekali sebagai peringatan, kami kemukakan pandangan YA Hakim Bicara di dalam kes *Charlotte Mary Erica Leng lwn. Anis Sani Bin Ariffin*, JH 47(2) bahawa kedua-dua pihak hendaklah mematuhi apa-apa perintah / penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah tanpa engkar agar proses

perlaksanaan perintah Mahkamah berjalan lancar. Kedua-dua pihak juga hendaklah memberikan kerjasama dalam memastikan kebajikan dan kemaslahatan anak tersebut terjaga tanpa halangan antara satu sama lain bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai ibu dan bapa kepada anak tersebut. Hargailah kurniaan anak kepada kita kerana ia adalah **AMANAH ALLAH** s.w.t. yang tidak ternilai.

[2] Kami juga kemukakan pandangan Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan di dalam kes ***Mohd Radhi bin Haji Che Daud lwn Khadijah binti Yaacob***, JH 17(1) sebagai renungan bersama iaitu -

“Tujuan hadhanah atau penjagaan kanak-kanak ialah untuk masalah dan kebaikan kanak-kanak yang dipelihara sebagai hak asasi bagi kanak-kanak itu dan hak itu mesti diutamakan lebih dari hak pihak yang ingin memelihara mereka.”

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan meneliti hujahan kedua-dua belah pihak, **MAKA KAMI MEMUTUSKAN** sebagaimana berikut -

1. Rayuan Perayu adalah **DITOLAK**.
2. Penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 4/9/2018 melalui **Kes Saman No. : 10200-026-0190-2016 DIKEKALKAN**.
3. Kos prosiding kes ini adalah ditanggung oleh masing-masing.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

